

1500566-96.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com a cominação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Com relação ao delito de associação para o tráfico, manifestou-se pela absolvição do denunciado.

A Defesa apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, por falta de provas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500566-96.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500566-96.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076206/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 16848837 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 484/21/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2076206 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICARDO APARECIDO DOMINGUES FREIRES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

RICARDO APARECIDO DOMINGUES FREIRES DA SILVA e SILVIO MENDES RIBEIRO REIS (desmembrado), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 17 de março de 2021, pela manhã, no endereço indicado na inicial, os denunciados venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, transportava, traziam consigo, guardavam, entregavam a consumo ou forneciam drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nos termos da inicial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Processada, a denúncia fora recebida, tendo havido determinação de futuro desmembramento com referência ao réu SILVIO MENDES (fls. 304). Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas, um informante e, ao final, o réu RICARDO APARECIDO foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com a cominação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Com relação ao delito de associação para o tráfico, manifestou-se pela absolvição do denunciado.

A Defesa apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, por falta de provas, ou, ainda, pela desclassificação para o crime de porte ilegal de drogas para uso pessoal, ressaltando que não houve qualquer comprovação de que tenha se operado o crime de associação para o tráfico de drogas.

DECIDO.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS;

No mérito, a ação penal deve ser julgada improcedente.

É que a caracterização do delito trazido pelo artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 não demanda a simples convergência de vontades para a prática das infrações contidas nos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas.

Na medida em que imprescindível faz-se a presença do denominado ânimo associativo, devidamente comprovado nos autos, porquanto se trata de figura integrante do tipo penal.

Compulsando os autos, especialmente a prova oral produzida, não se verifica a comprovação, a partir de elementos concretos, do vínculo de estabilidade, necessário para responsabilizar os acusados.

Ao contrário, observando as provas trazidas, não se denota, ainda que minimamente, circunstâncias suficientes, aptas a levar ao decreto condenatório.

Essencialmente porque, neste particular, a prova produzida em Juízo não trouxe a tranqüilidade necessária, e por isso, não serve de fundamento para eventual édito condenatório.

Sendo assim, existem apenas indícios, meras conjecturas, que não estão a demonstrar a imputação trazida na denúncia, culminando com a absolvição do acusado pela ofensa ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS;

No mérito, cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente, condenando-se o réu pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), pelo laudo toxicológico (fls. 375/377), pelo laudo pericial na necessaire e sacola apreendidas (fls. 357/362), pelo laudo pericial no manuscrito com a aparente

contabilidade do tráfico de drogas (fls. 363/365), pelas fotografias acostadas (fls. 110/111), pelo manuscrito apreendido (fls. 112) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando, na fase judicial, que estava no local apenas para adquirir drogas, sendo certo que o indivíduo de "camiseta vermelha foi quem correu", de modo que estava de camiseta vermelha "por coincidência."

O denunciado afirmou que, no instante em que chegou ao local dos fatos, visualizou SILVIO sendo preso, tendo identificado o menino com a camiseta vermelha, o SILVIO e um indivíduo chamado CAIO.

O réu disse que foi atendido pelo rapaz de camiseta vermelha, de modo que ele estava procurando a sacola, pois já tinha recebido o dinheiro (R\$ 20,00), ocasião em que, no momento em que os policiais chegaram pelos fundos, este indivíduo jogou o dinheiro, instante em que pegou os valores e colocou na cintura, esclarecendo que possuía, também, dinheiro na carteira.

O réu afirmou, ademais, que não correu, apenas saiu caminhando com uma sacola e um salgado dentro, tendo saído do lado oposto do rapaz de vermelho, acrescentando que LEONARDO veio conduzido pelos guardas, uma dos quais me pediu para voltar.

O réu falou que não estava junto com SILVIO, que saiu sozinho do bar, descrevendo que SILVIO foi agredido no interior da viatura, enquanto o carro estava estacionando no DP, com tapas, mãos no pescoço, quase até sufocar, e cano do revólver na costela, tendo reclamado para o policial BUENO sobre as agressões do "policial GCM moreno".

Por fim, o denunciado afirmou que era perseguido pelo guarda municipal MACHADO, que já o agrediu em outra oportunidade, tendo descrito, ainda, que, na presente abordagem, foi agredido com "graveto nas costas."

Contudo, suas alegações não encontram amparo na prova dos autos, eis que a prova oral colhida foi enfática em confirmar, sem sombras de dúvidas, o desenrolar fático apontado na denúncia.

Neste sentido, o guarda municipal CLAUDIO, na fase judicial, disse que estava em patrulhamento em campos de futebol, por conta das restrições decorrentes da pandemia, sendo certo que, nas proximidades do campo da SABESP, identificou quatro indivíduos.

O guarda municipal disse que eles se dispersaram em dois, sendo certo que, juntamente com HUDSON, abordou RICARDO, que vestia camiseta vermelha, e SILVIO, de modo que, no local de onde saiu, localizou uma sacola contendo uma bolsa preta com drogas, mais anotações relacionadas ao tráfico de drogas e dinheiro.

O guarda municipal afirmou que, em poder do réu RICARDO, localizou R\$ 34,00 em dinheiro na carteira e R\$ 20,00 na cintura, sendo certo que o LEONARDO e CAIO foram abordados por MACHADO e OLIVEIRA.

O guarda disse que LEONARDO e CAIO disseram que haviam comprado drogas do réu RICARDO por R\$ 10,00, tendo reafirmado que o local é ponto de venda de drogas.

O agente público falou que, em um primeiro momento, avistou os quatro indivíduos juntos, esclarecendo que o denunciado RICARDO afirmou que estava no local apenas

para comprar drogas.

Da mesma forma, foram as declarações do guarda municipal SILVIO, que, na fase judicial, confirmou a diligência e a abordagem de CAIO e LEONARDO, acrescentando que, no local dos fatos, houve a apreensão de diversas drogas, prontas para a venda, mais uma quantidade de dinheiro no interior da sacola.

O guarda municipal SILVIO disse, com todas as letras, que CAIO e LEONARDO afirmaram que adquiriram uma pedra de crack do réu RICARDO, sendo que o denunciado SILVIO falou que LEONARDO era o olheiro do tráfico de drogas.

Igualmente, o guarda municipal HUDSON, na fase judicial, afirmou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento para evitar aglomeração, no entanto, no campo de futebol, verificou que dois dos indivíduos separaram-se, ocasião em que abordou dois deles, RICARDO e SILVIO.

O guarda municipal chegou a afirmar que, nas proximidades de RICARDO (dois ou três metros), localizou uma bolsa contendo entorpecentes.

Seguindo essa linha, o guarda municipal ANTONIO EDSON DA SILVA MACHADO, na fase judicial, afirmou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento de fiscalização sobre comércios que descumpriam o decreto da pandemia.

O guarda municipal falou que, no campo da SABESP, local conhecido como ponto de venda de drogas, identificou quatro indivíduos se separando, tendo abordado CAIO e LEONARDO, de modo que "no ponto inicial, o colega FRANCISCO localizou uma sacola" contendo drogas, dinheiro e anotações.

O guarda confirmou que CAIO e LEONARDO disseram que haviam comprado duas pedras de crack de RICARDO, uma para cada um, sendo que SILVIO chegou a apontar LEONARDO como "estando envolvido com o tráfico."

Sobre o denunciado RICARDO, o guarda municipal disse que já havia prendido o réu pelo mesmo crime, negando que tivesse coagido LEONARDO e CAIO para acusar RICARDO, pois todos já haviam sido presos por tráfico de drogas, negando qualquer entrevista com os acusados ou, ainda, que, algum momento, tivesse dito que iria prender o acusado RICARDO, muito embora provavelmente tivesse abordado o réu.

Na fase investigativa, o guarda municipal trouxe versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos (fls. 07/11).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os guardas municipais tivessem trazido consigo drogas, prontas para serem comercializadas, mais dinheiro e um folha com anotações sobre a contabilidade do tráfico com o único propósito de forjar um ato de flagrante.

Não havendo nenhuma prova concreta que esteja a apontar que a diligência foi forjada, na medida em que não foi produzida nenhuma prova no sentido de, efetivamente, trazer contradições na versão dos agentes públicos.

Muito pelo contrário, a este respeito, a testemunha LEONARDO, na fase judicial,

disse que estava junto com CAIO, ocasião em que encontrou o réu RICARDO e outro indivíduo, chamado SILVIO ou SILVINHO.

A testemunha afirmou que todos estavam esperando o traficante pegar as drogas, dizendo que o traficante correu e largou a sacola, tendo ouvido que, por ter passagens pela polícia, o réu RICARDO iria responder pelos fatos.

A testemunha falou, ainda, que o rapaz de camiseta vermelha tinha corrido e que, em nenhum momento, acusou o réu RICARDO, não tendo tido sequer lido as declarações prestadas, negando que tivesse acusado o denunciado RICARDO.

A testemunha confirmou que encontrou na rua o denunciado RICARDO, tendo havido conversa a respeito, sendo certo que o réu RICARDO não estava de camiseta vermelha.

A testemunha disse que, no interior da mata, foi agredido pelos agentes públicos, pois não sabia quem seria o indivíduo de vermelho que correu, dizendo que ouviu que se não falassem, iriam ser todos acusados, de modo que, no DP, foram informados que "iriam jogar no RICARDO, pois ele já tinha passagem."

Sobre as agressões, a testemunha falou que todos foram agredidos, inclusive SILVIO, que foi agredido no interior da viatura, por um policial, com um galho de árvore, mencionando o nome do GCM MACHADO, bem como que as roupas foram queimadas.

Seguindo a mesma descrição, o informante SILVIO, na fase judicial, disse que é viciado em crack juntamente com o réu RICARDO, sendo que o denunciado RICARDO "desceu na trilha de baixo para comprar drogas e eu fiquei esperando", ocasião em que foi preso pelos policiais.

O informante deixou claro que "o cara que servia correu para o mato", tendo mencionado que foi obrigado a dizer que RICARDO era traficante, senão "iriam me colocar também mesmo assim", tendo esclarecido que, juntamente com RICARDO, LEONARDO e CAIO, foram agredidos pelos policiais.

O informante falou que as agressões deixaram marcas na região da perna, reafirmando que, por suas diversas passagens por tráfico de drogas, "quando me vêm na biqueira querem me colocar no tráfico".

Por fim, o informante alegou que, em nenhum momento, informou que o réu RICARDO estava traficando drogas, dizendo, inclusive, que o seu depoimento foi colhido no interior da viatura policial.

No entanto, analisando os laudos de exame de corpo de delito de todos os envolvidos (fls. 367, 369, 371 e 373), extrai-se que, nenhum deles, apontou ter havido lesão de interesse médico legal.

Ora bem, não seria razoável que os guardas municipais e os policiais civis, inclusive o Delegado de Polícia, estivessem em conluio com o perito que elaborou os laudos de exame de corpo de delito e nada identificou.

Esta peculiaridade acaba por enfraquecer a versão trazida pelos acusados, ainda mais, quando se considera que a testemunha LEONARDO afirmou que, após deixar a prisão, por ter sido solto durante a audiência de custódia, manteve contato com o réu RICARDO.

De mais a mais, não se pode desconsiderar que efetivamente existem indicativos de que o informante e a testemunha LEONARDO buscaram alterar a verdade dos fatos.

A este respeito, a testemunha LEONARDO, inicialmente, durante o seu depoimento na fase judicial, afirmou que o réu RICARDO não estava de camiseta vermelha, ao

contrário do que o próprio denunciado RICARDO disse na fase judicial, esclarecendo apenas após ter sido indagado pelo Ministério Público, que aquele indivíduo de camiseta vermelha foi quem teria corrido, o que se afigura mais do que suficiente para receber com reservas as suas declarações.

A reforçar este entendimento, cabe trazer à baila as contradições do informante, do réu e da testemunha LEONARDO sobre como estavam dispostos no local, assim sintetizadas pelo Ministério Público (fls. 409):

“Leonardo disse que estava junto com Caio quando encontrou com Ricardo e Silvio e, enquanto aguardavam o traficante apanhar as drogas, este fugiu sendo os demais abordados.

Já Silvio disse que permaneceu sentado esperando o traficante, e Ricardo foi busca a droga. Após, os Guardas apareceram de outra trilha, já com Leonardo e Caio, orientando-os a imutar a traficância a Ricardo.

Por fim, Ricardo disse que quando chegou ao local dos fatos, Silvio já estava sentando, junto com o traficante e Caio, sendo que Leonardo foi pego em outro local, no fundo da mata.”

Acerca da alegada suspeição do guarda municipal ANTONIO EDSON DA SILVA MACHADO, cabe salientar que não houve provas concretas da apontada perseguição, sendo certo que o fato de ter consultado a quantidade de entorpecentes apreendidos, como revelou durante o seu depoimento, em nada, faz concluir nesse sentido.

É que o artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que “não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.”

Em arremate, ainda sobre a questão da suspeição dos guardas municipais, deve-se destacar que inexistente qualquer indicativo nos autos de que as vestimentas dos envolvidos tivessem sido queimadas, cabendo considerar que, na fase investigativa, todos os envolvidos disseram que não houve qualquer “abuso ou violência policial durante a custódia” (fls. 12/15).

Fechando o conjunto probatório amplamente desfavorável ao denunciado, não se pode desconsiderar que os guardas municipais, tal como confirmou o próprio réu RICARDO, encontraram dinheiro na cintura do denunciado, a despeito de haver dinheiro em sua carteira, a colocar, ainda mais, em xeque e tornar fantasiosa a versão trazida pelo acusado de que teria pegado de volta o dinheiro, após o verdadeiro traficante ter fugido e jogado o dinheiro fora.

Por fim, cuidando-se de situação de flagrante delito, a atuação da Guarda Municipal revelar-se-ia cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

A este respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.507/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).”

Neste panorama, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte ilegal de entorpecentes.

É que o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas pressupõe a vontade livre e consciente de perpetrar qualquer dos verbos do tipo penal, acrescida do elemento subjetivo do injusto, ou seja, do dolo específico de manter em depósito drogas para consumo próprio.

No caso em exame, as peculiaridades acima mencionadas, somadas a forma pela qual as drogas foram apreendidas, tendo havido apreensão de folha com anotação relacionada à contabilidade do tráfico de drogas, sem desconsiderar que o local é ponto de venda de drogas, não estão a evidenciar nesse sentido.

Ao contrário, todas as provas produzidas revelam a atividade material descrita no tipo penal, no mínimo, consistente em vender e guardar drogas para entregar a consumo, conclusão que vem reforçada pelo fato de o réu ter sido condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 1500870-66/2019 (fls. 144), em 29 de abril de 2019, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido na alameda dos bandeirantes, n.º 17, Embu-Guaçu, local próximo à rua onde foi preso pela presente ação penal.

Em suma, a negativa do denunciado, desacompanhada de outras provas, acaba por ficar absolutamente isoladas diante do contexto probatório, sendo que a condenação do réu RICARDO pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Assim, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1/6 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação, em função dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 2334-73/2017 (fls. 144).

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em mais 1/6, em razão da reincidência do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 1500870-66/2019 (fls. 144), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, as peculiaridades do caso, especialmente o fato de o local ser conhecido ponto de venda de drogas, como afirmaram os agentes públicos, mais a quantidade e diversidade das drogas (fls. 26 – 44 porções de maconha, 81 pedras de crack, 9 lança-perfume e 249 pinos de cocaína), sem desconsiderar a existência de apreensão de folha com a contabilidade do tráfico (fls. 112), fazem concluir que se dedica a atividades criminosas, não se tratando de criminoso não habitual.

A respeito da possibilidade de utilização das circunstâncias da prisão, principalmente quando relacionada com identificação de se tratar o local de ponto de venda de drogas, para este fim, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA

ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Estatuto Repressivo, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

- No caso, a fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base era idônea. De fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 184,2g de maconha e 85,8g de cocaína - desbordavam do ordinário do tipo e autorizavam algum quantum de incremento punitivo. Porém, não no patamar aplicado, na origem, que fugia à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido, sem, contudo, explicitar qualquer razão especial que autorizasse o apenamento mais rígido, além do insito à circunstância judicial referida. Por isso, foi a ordem concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base do ora agravante para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, porquanto as instâncias de origem consignaram também que o ora agravante se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia militar que ele estaria traficando drogas (o que foi confirmado por seus vizinhos) -, as quais realmente sugerem que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, o apenado jus à aplicação da referida minorante. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

- O regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final (superior a 4 anos de reclusão e não superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Não há ilegalidade flagrante na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)."

A este respeito, indicamos o seguinte julgado da 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021.

Sobre os maus antecedentes criminais e a reincidência específica (fls. 144) como motivações idôneas para a negativa à aplicação da causa de diminuição, confira-se o seguinte julgado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.

3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) - o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 -, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1970177/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)."

Em suma, sob todos os ângulos analisados, possível concluir que não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, mais os seus maus antecedentes criminais e a sua reincidência específica, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 265/266), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Muito pelo contrário, não se pode desconsiderar que o réu descumpriu a medida cautelar de manter o seu endereço atualizado (fls. 252/253), fator que evidencia que a sua liberdade representa risco concreto para a aplicação da lei penal.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONDENO RICARDO APARECIDO DOMINGUES FREIRES DA SILVA, qualificado nos autos, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

ABSOLVO-O da imputação relacionada ao crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Certifique a serventia ter havido o desmembramento do feito com relação a LEONARDO e CAIO, ficando determinado o desmembramento do feito com referência ao réu SILVIO MENDES RIBEIRO REIS, devendo a serventia providenciar as respectivas citações, em razão da prisão de SILVIO e LEONARDO em outros autos.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.
Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.
Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA